

ZAHREE BIN KASIM @ ABU KASIM

Lwn

DEWANI BINTI ZOLKIFLI

[Mahkamah Rayuan Syariah Di Negeri Selangor, Y.A.A Dato' Haji Mukhyuddin Bin Ibrahim (Pengerusi), Y.A Dato' Haji Yusof Bin Musa (Panel), Y.A Tuan Haji Saarani bin Ismail (Panel), pada 18hb. Januari 2018]

[Kes Semakan Mal No. 10000-003-0086-2017]

Dalam Perkara: Semakan Perintah Hadhanah Interim Inter-Parte

Peguam Syarie Pemohon: *Tetuan Anuar Taufeq Junid & Associates*

Peguam Syarie Responden: -

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini adalah suatu permohonan Semakan yang difailkan oleh Zahree bin Kasim @ Abu Kasim (Pemohon) terhadap keputusan kes interim hadhanah secara inter-parte yang dikeluarkan oleh Mahkamah Tinggi Syariah Selangor di Shah Alam, kes mal no. 10300-038-0170-2017 pada 18/7/2017.

[2] Dalam kes ini, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk mendapatkan suatu Perintah seperti berikut;

- i. Bahawa Mahkamah yang mulis ini menyemak semula keputusan YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam melalui permohonan Interim Hadhanah kes no. 10300-038-0170-2017 bertarikh 18/7/2017.
- ii. Bahawa Mahkamah yang mulia ini menggantung perintah Interim Hadhanah, keputusan Hakim Bicara Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam, Selangor melalui saman no. 10300-038-0170-2017 bertarikh 18/7/2017 sehingga menunggu Mahkamah Rayuan Syariah memutuskan prosiding semakan kehakiman ini yang memerintahkan seperti berikut:-
 - a) Mahkamah memerintahkan agar anak pertama (Zakri Daniel bin Zahree) dan anak ketiga (Dyana Zalikha binti Zahree) diberikan membuat pilihan samada hendak tinggal dengan Pemohon atau Responden;
 - b) Mahkamah memerintahkan bagi anak kedua, keempat, kelima dan keenam diberikan hak jagaan sementara kepada Pemohon;
 - c) Mahkamah memerintahkan Responden diberikan hak untuk lawatan dan bersama dengan anak-anak kedua, keempat, kelima dan keenam pada bila-bila masa yang sesuai dan munasabah dengan kemahuan anak-anak tersebut dan dimaklumkan awal kepada Pemohon.
- iii. Apa-apa relif yang difikirkan patut dan sesuai oleh Mahkamah Yang Mulia ini.

Fakta Kes

[3] Dalam permohonan semakan ini, Pemohon telah tidak berpuas hati dengan perintah interim kes mal no. 10300-038-0170-2017 dengan alasan sejak Pemohon dan Responden bercerai pada Mei 2012, anak-anak tersebut telah dijaga dengan baik dan sempurna oleh Pemohon. Menurut Pemohon adalah tidak wajar dan mendatangkan kesulitan yang besar sekiranya Responden diberikan hak jagaan sementara tersebut kerana Responden selalu mengabaikan kebajikan anak-anak tersebut.

[4] Selain itu, Pemohon menyatakan bahawa Responden seorang ibu yang berkelakuan buruk dan tidak kompeten untuk mendapat hak jagaan anak sementara. Responden pernah ditangkat khalwat bersama seorang lelaki yang bukan mahram pada 1/12/2011.

[5] Bagi menjelaskan pertikaian yang ditimbulkan Pemohon, Kami telah memanggil rekod kes mal no. 10300-038-0170-2017 yang berkaitan dan kami ringkaskan kronologi kes sebagaimana berikut;

Bil.	Tarikh	Peristiwa
1.	16/3/2017	Responden failkan Permohonan Hadhanah Interim di Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam kes mal no. 10300-038-0170-2017
2.	16/3/2017	Responden failkan Notis Perakuan Segera untuk Mahkamah memutuskan permohonan hadhanah interim tersebut.

3.	16/3/2017	Prosiding Mendengar Notis Perakuan Segera di hadapan Pendaftar Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam. Mahkamah menolak permohonan tersebut atas alasan tiada unsur-unsur keterdesakan.
4.	17/3/2017	Penyampaian Notis Permohonan & Affidavit Permohonan kes mal no. 10300-038-0170-2017 kepada Pemohon secara kediri (Rujuk Affidavit Penyampaian oleh Mahkamah bertarikh 21/3/2017).
5.	21/3/2017	Sebutan kali-1 Pemohon, Peguam Syarie & Responden (tanpa peguam) hadir. Mahkamah arahkan pihak Responden failkan Afidavit Jawapan.
6.	6/4/2017	Responden failkan Afidavit Tambahan di Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam bagi kes mal no. 10300-038-0170-2017.
7.	27/4/2017	Sebutan kali-2 Pemohon, Peguam Syarie & Responden, Peguam Syarie hadir. Penyerahan Afidavit Tambahan kepada Responden. Mahkamah tangguhkan untuk sebutan semula bagi memberi peluang Responden menjawab Afidavit Tambahan.
8.	23/5/2017	Sebutan kali-3 Pemohon, Peguam Syarie & Responden, Peguam Syarie hadir. Mahkamah arahkan Pemohon memfailkan Afidavit Balasan sebelum atau pada 31/5/2017 dan pihak-pihak diarahkan memfailkan hujah sebelum atau pada 16/6/2017.
9.	18/7/2017	Pemohon, Peguam Syarie & Responden hadir, Peguam

		Syarie Responden tidak hadir. Mahkamah memerintahkan hak hadhanah interim ke atas Responden sehingga perintah kes induk hadhanah kekal diputuskan.
11.	3/8/2017	Pemohon menfailkan permohonan semakan di Mahkamah Rayuan Syariah Selangor.

Alasan Mahkamah Rayuan Syariah

[6] Secara umumnya permohonan untuk menyemak suatu keputusan interim sama ada secara *inter-parte* atau *ex-parte* yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Tinggi Syariah, kami merujuk kes *Norsyaqirene Bt. Ramli lwn. Afifi Bin Aminuddin kes mal No. 05000-003-0005-2015*, di Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Sembilan pada 22/5/2015 (*belum dilaporkan*). Kes tersebut telah menjadikan Arahan Amalan No.9 Tahun 2006 sebagai panduan utama, sebagaimana berikut:

“...telah bersetuju dan mengesahkan untuk menerima pakai arahan amalan bahawa permohonan semakan ke atas keputusan dan perintah ex-parte adalah tidak dibenarkan selagi kes induk masih belum diselesaikan. Pihak-pihak yang terkilan hendaklah memfailkan Notis Rayuan ke atas kes induk tersebut.”

[7] Arahan Amalan tersebut menyatakan perintah yang tidak boleh disemak adalah Perintah *ex-parte*, namun prinsipnya juga boleh terpakai kepada kes

interparte dan perhatian utama yang mesti diberi perhatian ialah ialah tujuan kenapa ia tidak boleh disemak?

[8] Tujuan Arahan Amalan No.9 Tahun 2006 itu digubal ialah untuk mengelakkan perbicaraan kes induk mengambil masa yang lama kerana diganggu oleh sesuatu prosiding permohonan sampingan. Ianya juga di atas prinsip sesuatu perintah sementara (interim) itu hanya bersifat sementara sahaja sehingga keputusan/perintah muktamad dibuat melalui kes induk.

[9] Walau bagaimanapun terdapat pengecualian kes-kes interim inter-parte ini boleh disemak iaitu apabila ternyata berlaku salah aturan yang menjejaskan keadilan atau sesuatu keputusan tersebut menyalahi hukum syarak yang bersifat *qatie* (muktamad) dan/atau peruntukkan undang-undang, sebagaimana *kes Mohd Fauzi bin Yaacoob lwn. Zabedah binti Hanapiah kes Mal (Semakan) No. 10000-003-0009-2010* yang diputuskan oleh Mahkamah Rayuan Syariah Selangor pada 20-9-2010 (belum dilaporkan) dan *kes Mokhtar b. Yusup lwn. Nurin bt. Abdullah, Kes Mal (Semakan) No.14000-003-0035-2011* yang diputuskan oleh Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan pada 07/03/2012 yang menyatakan seperti berikut:

“Proses semakan semata-mata untuk menyemak apa-apa kesilapan dalam proses membuat keputusan yang menjejaskan keadilan atau keputusan yang jelas menyalahi Nas-Nas Syarak yang qatie atau jelas berlawanan dengan Undang-Undang yang sedangberkuatkuasa.”

[10] Sebelum kami mengulas lanjut berhubung dengan permohonan Pemohon, kami dapati bahawa anak-anak yang menjadi isu pertikaian di antara Pemohon dan

Responden kini telah berumur 19 tahun (lelaki), 18 tahun (lelaki), 14 tahun (perempuan), 13 tahun (perempuan), 11 tahun (lelaki) dan 10 tahun (lelaki) yang mana jelas telah mencapai umur kecerdikan (*mumaiyyiz*) menurut hukum Syarak dan undang-undang.

[11] Dalam hal ini, suka untuk kami perturunkan di dalam kitab *al Umm*, oleh Imam al-Shafie, jilid 3, Beyrut, Lebanon menyebutkan:-

: فإذا افترق الأبوان وهما في قرية واحدة فالأم أحق بولدها مالم تتزوج وماكانوا صغارا فإذا بلغ أحدهم سبعا أو ثمانا سنين وهو يعقل خير بين أبيه وأمه وكان عند أيهما اختار

Maksudnya:

"Apabila berpisah kedua ibu bapa dan kedua-duanya berada dalam satu qariah maka ibu adalah lebih berhak terhadap anaknya selama ia belum berkahwin lain dan semasa anak-anak itu masih kecil. Apabila genap umur mereka tujuh tahun atau lapan tahun dan ia sempurna akal ia disuruh pilih di antara bapa dan ibunya dan ia akan bersama dengan siapa yang dipilih." (Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin idris , Al-Umm, Juzuk 5 m.s. 99)

[12] Di dalam kitab *Al-Muhazzab*, Juzuk 2 hal. 171: *Mughni al-Muhtaj* Juzuk 3 hal. 456 disebut maksudnya:-

"Apabila berlaku perpisahan antara suami isteri dan mereka mempunyai seorang anak yang mumayyiz sama ada lelaki atau perempuan dan sudah mencapai umur tujuh atau lapan tahun. Kedua-dua suami-isteri ini pula layak

menjaga anak (hadhanah) walau salah seorang daripada kedua mereka lebih baik dari sudut agama, harta benda atau kasih sayang, dan mereka tidak sepakat kata, anak itu hendaklah diberi pilihan antara kedua mereka dan tinggal bersama dengan ibu bapa yang dipilihnya. Kerana Baginda Nabi s.a.w. telah memberi pilihan kepada seorang anak lelaki antara bapa dan ibunya".(Mughni Al Muhtaj Juzuk 3 hal 456; Al Fiqh al Islami wa Adillatuhu Juzuk 7 edisi 3 1409-1949 hal. 743).

[13] Dalam ***Fiqh al-Sunnah*** Juzuk 2 1415/1995 hal. 234 disebut maksudnya:

"Seorang wanita datang menemui Rasulullah s.a.w. katanya: Ya Rasulullah, sesungguhnya suami (bekas) saya mahu mengambil anak saya dan ia telah mampu membawa air untuk saya dari telaga Abi Inabah dan ia banyak memberi faedah kepada saya. Baginda Rasulullah s.a.w bersabda, "Ini bapa kamu dan ini pula ibu kamu, pilihlah satu daripada kedua-dua mereka". Anak itu memilih ibunya dan mereka pergi dari situ. (Lihat Sunan Abu Daud, Kitab Al Talaq)

[14] Ini bermakna pemilihan anak-anak yang telah berumur 7 tahun ke atas adalah diharuskan oleh hukum Syarak. Seksyen 85 Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 (EUUKIS 2003) juga telah memperuntukkan bahawa tempoh hadhanah ke atas seorang kanak-kanak tamat apabila kanak-kanak lelaki mencapai umur 7 tahun dan kanak-kanak perempuan apabila berumur 9 tahun. Kami perturunkan peruntukan seksyen 85 sebagaimana berikut:-

Seksyen 85

Lamanya penjagaan.

- 1) ***Hak hadinah*** bagi menjaga seseorang kanak-kanak adalah ***tamat*** setelah kanak-kanak itu mencapai ***umur tujuh tahun, jika kanak-kanak itu lelaki, dan umur sembilan tahun, jika kanak-kanak itu perempuan, tetapi Mahkamah boleh, atas permohonan hadinah, membenarkan dia menjaga kanak-kanak itu sehingga kanak-kanak itu mencapai umur sembilan tahun, jika kanak-kanak itu lelaki, dan umur sebelas tahun, jika kanak-kanak itu perempuan.***
- 2) ***Setelah tamatnya hak hadinah, penjagaan adalah turun kepada bapa, dan jika kanak-kanak itu telah mencapai umur kecerdikan (mumaiyiz), maka kanak-kanak itu adalah berhak memilih untuk tinggal dengan sama ada ibu atau bapanya, melainkan jika Mahkamah memerintahkan selainnya.***

[15] Berbalik kepada kes di hadapan kami ini, setelah meneliti permohonan dan affidavit Pemohon serta memanggil rekod perbicaraan kes mal no. 103-038-0170-2017, kami dapati Pemohon telah mempersoalkan keputusan Hakim Bicara Mahkamah Tinggi Syariah namun Pemohon tidak ada menyatakan tentang kesalahaturan yang nyata, terjejasnya keadilan dan tidak menyatakan tentang apa-apa perintah Hakim Bicara tersebut yang telah menyalahi hukum syarak atau undang-undang. Oleh yang demikian, Pemohon telah gagal memberikan sebarang alasan syarak dan undang-undang berkenaan dakwaan berlakunya kekhilafan Hakim Bicara semasa memutuskan perintah interim tersebut

[16] Di peringkat ini, kami berpuashati bahawa kami tidak menemui apa-apa perintah yang menyalahi hukum syarak dan undang-undang serta tiadanya kecacatan atau salah aturan prosiding sepanjang kes tersebut berjalan mengikut hukum syarak dan undang-undang yang menjejaskan keadilan. Oleh yang demikian, kami tidak mempunyai apa-apa alasan untuk kami campurtangan selain mengekalkan perintah kes mal no. 10300-038-0170-2017 bertarikh 18/7/2017 tersebut.

[17] Demi kebajikan anak-anak tersebut juga, kami menegaskan bahawa pertikaian antara Pemohon dan Responden di dalam kes induk perlulah disegerakan. Permohonan yang bersifat interlokutori selepas ini seboleh-bolehnya tidak digalakkan kerana ianya boleh melambatkan penyelesaian muktamad di dalam kes induk.

KEPUTUSAN

SETELAH Kami membaca, meneliti permohonan semakan Pemohon dan setelah menyemak rekod kes no. 10300-038-0170-2017, MAKA Kami sebulat suara memutuskan bahawa :-

- [1] Permohonan semakan oleh Pemohon **DITOLAK**.
- [2] Perintah kes mal no. 10300-038-0170-2017 bertarikh 18/7/2017 **DIKEKALKAN**.
- [3] Prosiding kes induk di Mahkamah Tinggi Syariah Selangor Di Shah Alam hendaklah **DISEGERAKAN**.

Penghakiman ini diberikan oleh:-

-
1. **Y.A.A DATO' HAJI MUKHYUDDIN BIN IBRAHIM**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-

-
2. **Y.A DATO' HAJI YUSOF BIN MUSA**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-

-
3. **Y.A TUAN HAJI SAARANI BIN ISMAIL**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

